

포괄임금제에 관한 법적 성격과 쟁점

김 홍 석

법학 박사, 건국대학교 법학연구소 책임연구원

[목 차]

- | | |
|------------------|----------------------|
| I. 문제의 제기 | IV. 포괄임금제의 개선을 위한 방안 |
| II. 포괄임금제의 법적 의의 | V. 결론 |
| III. 포괄임금제의 쟁점 | |

I. 문제의 제기

근로기준법에서 임금 관련 규정은 기본임금을 미리 정하고 이를 기반으로 연장 및 휴일, 야간근로 등에 관하여 가산수당을 별도로 지급하는 형태를 가지고 있다.

근로기준법 제17조에서는 근로조건을 체결할 시 사용자가 근로자에게 임금, 소정근로시간, 제55조에 따른 주휴일, 제60조에 따른 연차 유급휴가 등의 근로조건을 명시하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 근로기준법 제56조에서는 가산임금과 관련하여 제1항에서는 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하고, 제2항에서는 휴일근로와 관련하여 8시간 이내는 통상임금의 100분의 50을, 8시간을 초과하는 휴일근로는 통상임금의 100분의 100을 지급하도록 규정하고 있다.

■ 투고일자 : 2023.5.11. 심사종료일자 : 2023.5.17. 게재확정일자 : 2023.5.30.

제3항에서는 야간근로에 대하여 100분의 50 이상을 가산하여 지급하도록 규정하고 있다.

가산임금과 관련하여 법에서 규정하고 있음에도 불구하고, 판례는 근로 시간 수에 상관없이 근로자에게 일정한 금액만을 지급하는 이른바 포괄 임금제를 유효하다고 인정하고 있다.¹⁾ 현실적 편의성이라는 측면에서 인정되어 온 포괄임금제는 그 자체로 많은 문제점을 가지고 있다. 근로 현장에서 포괄임금제는 근로자에게 실질적으로 임금을 하락시키는 원인이 되고, 온전하게 휴식권을 보장해야 하는 휴가 제도를 무의미하게 만들며 장시간 근로로 이어지는 원인이 되고 있다.

이러한 문제점들로 인해 포괄임금제는 근로기준법에서 규정하고 있는 근로시간 및 법정수당, 가산임금에 관한 규정들을 무의미하게 만드는 제도로 비판받고 있다. 이러한 비판으로 인해 대법원은 과거 폭넓게 인정하던 포괄임금제를 점차 제한적으로 해석하고 있다. 대표적으로 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니면 차액 지급 청구를 인정한다거나, 계산의 편의와 근로자의 근로의욕 고취라는 표현을 사용하지 않는다고나 묵시적 근로계약의 성립을 매우 제한적으로 허용하고 있는 것 등이 그 예라고 볼 수 있다.

판례의 변화에도 불구하고 여전히 근로 현장에서 포괄임금제는 상당수 사업장에서 근로자에게 불이익한 제도로 성행하고 있다. 근로자에게 헌법에서 규정하고 있는 인간다운 삶을 보장하기 위해서는 포괄임금제에 대한 개선이 필요한 실정이다.

근로 현실에서 다양한 문제점을 내재한 포괄임금제에 대한 해결책을 찾기 위해 본 글에서는 학설 및 판례를 중심으로 포괄임금제의 쟁점에 대하여 살펴본다.

이하에서는 판례법리로 발전한 포괄임금제의 법적 의의를 살펴본 후, 성립요건에 대하여 살펴본다. 또한, 적용 대상 및 유효요건에 대하여 학설을 중심으로 검토한 후 개선방안으로 그 해결책을 찾도록 한다.

1) 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 『성균관법학』, 제23권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2011, 845면.

II. 포괄임금제의 법적 의의

1. 포괄임금제의 개념 및 의의

포괄임금제는 근로자와 사용자가 임금 산정 방법을 정하면서 일정 항목의 임금을 따로 산정하지 않은 채 다른 항목의 급여에 포함시켜 일괄하여 지급하기로 하는 임금 지급 방식을 말한다.²⁾ 포괄임금제가 실현되기 위해서는 근로계약 및 취업규칙, 단체협약 등에 규정이 있어야 한다.³⁾

근로기준법 제17조(근로조건 명시)와 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)는 포괄임금제와 직접 관련이 있는 조항이다. 근로기준법 제17조에서는 임금 및 소정근로시간 등에 관한 근로조건 명시 원칙을 규정하고 있다.⁴⁾ 근로기준법 제17조의 위임 규정인 근로기준법 시행령 제8조는 근로기준법 제93조 제1호부터 제12호까지 규정에서 정한 사항 등을 명시해야 할 근로조건으로 정하고 있다.⁵⁾ 명시해야 할 근로조건에는 ‘임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정 기간·지급 시기 및 승급’과 ‘가족수당의 계산·지급 방법’ 등이 포함된다.⁶⁾

2) 노동법실무연구회, 근로기준법주해Ⅲ, 제2판, 박영사, 2020, 275-276면.

3) 포괄임금제의 실시 규정 중 근로계약은 47.1%, 취업규칙은 43.5%, 단체협약은 5.9% 정도를 차지하고 있다.; 정동관 외, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, 한국노동연구원, 2016, 52면 참조.

4) 근로기준법 제17조(근로조건 명시) ① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 임금
2. 소정근로시간
3. 제55조에 따른 휴일
4. 제60조에 따른 연장 유급휴가
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건

② 사용자는 제1항 제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다.

5) 임상민, “포괄임금제의 성립 및 유효요건”, 『인권과 정의』, 제502호, 대한변호사협회, 2021, 98면.

근로기준법 제56조에서는 연장·야간 및 휴일근로에 관한 가산임금을 규정하고 있다.⁷⁾ 근로기준법 제17조, 제56조는 최저근로조건으로써 강행 규정이다.⁸⁾ 근로기준법 제17조 및 제56조에 따르면 사용자는 근로계약을 체결함에 있어 기본임금을 결정해야 하고, 이를 토대로 근로자의 실근로 시간에 따라 연장·야간·휴일근로가 발생하면 연장·야간·휴일근로에 대한 법정수당을 가산하여 지급하여야 한다. 구체적인 임금의 결정이나 계산, 지급 방법 등은 미리 명시되어야 한다.

즉, 근로기준법에서는 임금의 양적·질적 요소를 모두 고려하여 기본임금을 정한 후 이를 토대로 법정수당을 계산하여 합산하는 방식으로 임금산정방식을 예정하고 있다.⁹⁾ 하지만 현실에서는 업종의 특성에 따라 탄력적으로 임금을 운용하는 관행이 만들어졌고 판례가 이를 허용하게 됨으로써 포괄임금제 법리가 만들어졌다.

대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결은 기본임금을 결정하고 이를 기초로 연장·야간·휴일근로 수당 등 제 수당을 가산하여 지급하는 구조에 대한 예외로 사업장의 관행을 인정하였다. ‘포괄임금제’라는 용어가 사용되기 시작한 것은 1990년대 중반 이후 보편적으로 사용하고 있다. 학계에서는 포괄역산임금제¹⁰⁾, 포괄산정임금제¹¹⁾, 포괄임금계약¹²⁾, 포괄임금산

6) 임상민, 앞의 논문, 98면.

7) 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일근로) ① 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

8) 강성태 교수는, 근로조건 명시 의무는 사용자에게 공법적인 의무만 부과하는 것이 아닌, 근로계약의 내용이 당사자 간의 다툼이 있거나 불명확한 경우, 명시 의무를 가지고 있는 사용자가 위험을 감수해야 한다는 것이 명시 의무의 사법적 효력이라고 본다.; 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 『노동법연구』, 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2008, 271면.

9) 임상민, 앞의 논문, 98면 참조.

10) 김수근, “포괄역산 관행의 문제”, 『월간 경영계』, 전국경영자총협회, 1996, 20면, 박주현, “포괄산정근로계약(포괄역산임금계약)과 근로시간”, 『노동법연구』, 제2권 제1호, 서울대학

정제¹³⁾ 등의 명칭으로 불리기도 한다.

포괄임금제와 관련하여 학계에서는 장시간 노동의 계기가 되고, 저임금을 양산한다는 측면에서 제한 및 금지해야 한다는 주장들이 꾸준히 제기되고 있다.¹⁴⁾ 판례 역시 2009년 이후 포괄임금제의 성립 및 유효성에 대하여 과거보다 엄격한 기준을 설정, 판단하고 있다.¹⁵⁾

포괄임금제 성립과 관련하여 판례는, 포괄임금제 약정이 사용자와 근로자 양 당사자 사이에 성립했는지 여부는 근로 형태와 업무의 성질, 근로시간, 취업규칙 등의 내용, 임금 산정의 단위, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 종합하여 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고,¹⁶⁾ 개별 사안에서 업무의 성격이나 근로 형태상 연장근로 등이 사전에 당연히 예상되더라도 연장근로수당 등을 세부 항목으로 구분하여 지급하도록 취업규칙에서 정한 경우 포괄임금제에 해당하지 않는다.¹⁷⁾ 또한, 포괄임금제의 성립을 인정하기 위해서는 근로 형태의 특수성으로 실근로시간을 명확하게 산정하기 곤란하거나 일정한 연장근로 등이 예상되는 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간 및 정해진 임금의 수준이나 형태 등 제반 사정에 비추어 소정의 일급액이나 월급액 이외에 어떠한 수당도 지급하지 않거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 한 합의가 있었다고 인정되어야 한다.¹⁸⁾

교 노동법연구회, 1992, 299면, 이병태, 최신노동법, 제8판, (주)중앙경제, 2008, 597면.

11) 박주현, 앞의 논문, 299면, 이공희, “포괄산정임금제의 적용과 근로기준 판단”, 『노동교육』, 제37호, 한국노동교육원, 2003, 151면, 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 『인권과 정의』, 제347호, 대한변호사협회, 2005, 57면.

12) 이재용, “근로시간의 산정이 어려운 사정이 없는 경우 포괄임금계약의 효력”, 『법학연구』, 제43집, 한국법학회, 2011, 374면.

13) 이상윤, 노동법, 제6판, 법문사, 2011, 244면.

14) 강성태, 앞의 논문, 269면, 김홍영, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나 자료집, 2019, 12, 3면, 이석, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나 자료집, 2019, 12, 2면.

15) 임종률, 노동법, 제19판, 박영사, 2021, 477면.

16) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결.

17) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결.

18) 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결.

2. 포괄임금제의 유형

판례에 의해 포괄임금제를 구분해보면, 기본임금을 미리 산정하는지에 따라 ① 기본임금을 미리 산정하지 않고 시간외근로 등에 대한 제 수당을 합한 금액을 일급여액이나 월급여액으로 정하는 유형(정액급제)와 ② 매월 일정액을 제 수당으로 지급하는 유형(정액수당제)으로 나눌 수 있다.¹⁹⁾

예를 들어, 월 급여가 400만원이라면, 정액급제는 기본임금과 제 수당을 특정하지 않고 모두 포함하여 급여가 400만원이 된다. 정액수당제는 제 수당 산정의 기준이 되는 기본급은 정해져 있지만, 제 수당은 구체적인 내역을 특정하지 않고 일정한 총액으로 급여를 지급하는 유형이다. 기본급이 월 300만원으로 정해져 있다면, 제 수당은 기본급과 별개로 월 100만원으로 정해져 있는 경우이다.

언급한 두 가지 유형 중 기본급조차 정해져 있지 않은 정액급제는 근로기준법 위반의 소지가 크다. 포괄임금제를 인정하는 입장에서도 정액급제와 관련하여 견해의 대립이 발생한다.

우선 부정설의 입장은, 기본급과 제 수당의 지급액을 구분할 수 없기에 임금의 지급 방법 및 계산 방법, 구성항목에 관하여 사용자에게 명시 의무를 부여하고 있는 근로기준법 제17조에 위반되어 무효라고 보는 견해이다.²⁰⁾

이에 반해 긍정설의 입장은, 근로계약 또는 단체협약에 기인한 것이고 해당 근로자에게 실질적으로 불이익이 발생하지 않는 이상, 근로기준법에 반하여 무효라고 볼 수 없다고 보는 견해이다.²¹⁾

이와 관련하여 판례는, “기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 제 수당을 합한 금액을 월급여액이나 일당 임금으로 정하거나 매월 일정액을 제 수당으로 지급하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금지급계약을 체

19) 노동법실무연구회, 앞의 책, 276면.

20) 김도형, “포괄임금약정에 관한 판례 법리의 검토”, 『노동판례 비평』, 제15호, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2011, 189-191면, 김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리”, 『법과 정책연구』, 제20집, 한국법정책학회, 2020, 146-147면.

21) 하갑래, 근로기준법, 제25판, 중앙경제사, 2013, 445면.

결한 경우에 그것이 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를 무효라고 할 수 없다”라고 판시²²⁾하여 정액급제를 인정하는 유효설의 입장을 취하고 있다.

3. 포괄임금제의 성립요건

포괄임금제와 관련하여 우선적으로 검토해봐야 할 것은 어떤 경우 포괄임금제가 성립하는지이다. 포괄임금제의 성립요건과 관련하여 유효요건과 동일하게 파악하는 견해가 존재한다.²³⁾ 그러나 포괄임금제가 성립되지 않는 경우 포괄임금제의 유효 여부는 당연히 따질 필요가 없기에 포괄임금제의 성립요건과 유효요건은 구분하여 판단해야 한다. 이하에서는 성립요건에 대하여 살펴본다.

(1) 묵시적 합의에 따른 성립 여부

포괄임금제 약정이 성립하기 위해서는 당사자 간 합의가 있어야 한다.²⁴⁾ 포괄임금제 임금 약정이 예외적으로 인정되고, 근로기준법 제17조에서 임금의 구성항목 및 계산 방법, 지급 방법 등을 명시하고 있는 점을 근거로 구두 또는 서면에 의한 명시적 합의를 요한다는 견해도 존재한다.²⁵⁾ 하지만 포괄임금제가 예외적으로 인정되는 제도라는 점에 비춰보면 근로조건의 명시가 근로계약의 성립요건이라고 보기에는 어려우므로 묵시적 합의에 의한 포괄임금제 약정 성립은 가능하다고 볼 수 있다.²⁶⁾ 판례 또한 묵시적 합의에 의한 포괄임금제 약정 계약이 가능하다고 본다.²⁷⁾

22) 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결.

23) 노동법실무연구회, 앞의 책, 279면 참조.

24) 임종률, 앞의 책, 478면.

25) 박주현, 앞의 논문, 306면, 송명호, 앞의 논문, 75면.

26) 문형배, “포괄임금계약과 근로기준법 제61조”, 『판례연구』, 제11집, 부산판례연구회, 2000, 718면.

27) 대법원 1991. 4. 9. 선고 90다16245 판결.

(2) 성립 여부 판단의 기준

포괄임금제에 따른 임금 약정 계약 여부에 대한 명시적 합의가 인정되지 않는 경우, 어떠한 내용의 합의가 있을 시 포괄임금제 임금 약정 계약이 성립되는지 문제가 발생한다. 판례는 포괄임금제 약정 성립을 판단하기 위해서는 근로형태와 업무의 성질, 근로시간, 단체협약 및 취업규칙의 내용, 임금 산정의 단위 등 여러 사정들을 종합적·전체적으로 고려, 구체적으로 판단해야 한다고 한다.²⁸⁾ 또한, 개별 사안들에 대해서는 근로 형태나 업무의 성격상 연장 및 야간, 휴일 근로가 당연히 예상되어도 기본급과는 별도로 연장 및 야간, 휴일 근로 수당 등을 세부 항목으로 상세히 나누어 지급하도록 취업규칙 및 단체협약, 급여 규정 등에서 규정하고 있는 경우 포괄임금제에 해당하지 아니하고, 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과하는 연장근로시간에 대한 합의가 있거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 포괄임금제에 관한 합의가 존재한다고 설불리 단정할 수는 없다고 본다.²⁹⁾

또한, 근로자가 수년간 이의 제기 없이 포괄임금제 약정에 따라 임금을 수령 하였다면, 이는 묵시적 합의에 해당하여 간접 사실로 인정된다는 것이 다수 견해이지만,³⁰⁾ 수년간 이의 제기 없이 임금을 수령 하였다면 사실만으로 근로계약 체결 시 포괄임금제에 의한 임금 지급 방식을 근로자가 묵시적으로 승낙하였다고 보기에는 한계가 존재한다.³¹⁾

근로 형태의 성질과 관련하여 판례는 “단체협약 및 취업규칙이나 근로계약서에 포괄 임금이라는 취지를 명시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금 약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는 근로 형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정

28) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결.

29) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57582 판결.

30) 신수길, “포괄임금제에 의한 임금지급계약이 유효하기 위한 요건”, 『대법원판례해설』, 제32호, 법원도서관, 1999, 193면, 문형배, 앞의 논문, 718면.

31) 송명길, 앞의 논문, 75면.

될 뿐만 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 그 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 한다.”라고 판시³²⁾하고 있다. 판례에 의하면 묵시적 합의에 의한 포괄임금제 약정이 유효 하려면 충족 요건이 엄격해야 한다는 것을 알 수 있다.

Ⅲ. 포괄임금제의 쟁점

이하에서는 앞서 언급한 포괄임금제의 이론적 배경을 토대로 포괄임금제와 관련한 쟁점에 대하여 살펴본다.

포괄임금제의 임금 약정 성격과 관련하여 포괄임금제의 법적 성격인 예외적 인정설과 예외적 부정설, 복수 유형설에 대하여 살펴본다. 또한, 포괄임금제의 적용 대상 여부와 관련하여 적용 대상을 제한할 수 있다는 대상 제한론과 제한할 필요가 없다는 불이익성론에 대하여 학설 및 판례를 중심으로 살펴본다.

1. 포괄임금제의 임금 약정의 성격

포괄임금제의 임금 약정의 성격과 관련하여 3가지 견해로 나뉜다. 포괄임금제의 임금 약정이 예외적으로 인정된다는 예외적 인정설과 인정되지 않는다는 예외적 부정설, 절충설의 입장인 복수유형설이 있다. 이러한 견해의 대립은 포괄임금제의 적용 대상과 관련하여서도 다툼이 존재한다.

32) 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1069 판결.

(1) 예외적 인정설

예외적 인정설은 판례에 의해 예외적으로 인정된다는 견해이다.³³⁾ 그 근거로는, 근로기준법 제17조에 의하면 사용자는 근로계약을 체결할 시 임금을 명시해야 하고, 임금의 구성항목 및 지급 방법, 계산 방법, 소정근로시간에 관한 사항은 서면으로 명시해야 한다는 것, 근로기준법 제56조에 의하면 사용자는 연장·야간·휴일 근로에 대해 가산임금 지급이 원칙인 것, 근로기준법 제15조에서 규정하는 법의 강행적 효력과 보충적 효력 등에 비추어 보면 포괄임금제는 근로기준법의 강행 규정성 원칙 위에서 일정한 요건을 갖춘 예외적인 경우에 한하여 그 유효성이 인정된다는 제도라는 점을 들고 있다.³⁴⁾

예외적 인정설은 포괄임금제가 인정되는 경우를, “근로시간 및 근로 형태와 업무의 성질상 실제 근로시간의 산출이 어려운 경우”³⁵⁾ 이거나 “근로기준법의 근로시간, 휴일·휴가 등에 관한 규정을 그대로 적용하기 곤란하거나 적용할 필요가 없는 경우”³⁶⁾로 판단하고 있다.

(2) 예외적 부정설

예외적 부정설은 근로계약 당사자가 포괄임금 약정을 자유롭게 정할 수 있는 임금 약정의 한 형태라고 보는 견해이다.³⁷⁾ 즉, 이 견해에 따르면 판례가 언급하는 “근로자에게 불이익이 없는지” 여부는 임금 약정에 단체협약, 취업규칙, 강행규정 등을 위반하여 근로자에 대한 불이익이 있는지 여부를 말할 뿐, 다른 특별한 기준을 제시하는 것은 아니라고 보는 견해이다.

33) 노동법실무연구회, 앞의 책, 281면.

34) 문형배, 앞의 논문, 716면, 박주현, 앞의 논문, 305-306쪽, 이국환, “감시단속적 근로와 포괄임금계약의 유효성”, 『대법원판례해설』, 제28호, 법원도서관, 1997, 349면, 송명호, 앞의 논문, 59면.

35) 문형배, 앞의 논문, 716면, 이국환, 앞의 논문, 349면.

36) 송명호, 앞의 논문, 59면.

37) 김지형, “노동쟁송과 판례연구(하)”, 『인권과 정의』, 제319호, 대한변호사협회, 2003, 164면.

(3) 복수 유형설

복수 유형설은 포괄임금제가 성격이 다른 복수의 유형으로 구성된 제도라고 보는 견해이다.³⁸⁾이 견해에 의하면 예외적 인정설은 요건을 충족하지 못하는 포괄임금계약은 포괄임금제라는 개념에서 제외되고, 다른 이름으로 개념을 정의해야 하는 문제가 발생한다고 언급한다. 또한 예외적 부정설에 대해서는 “근로시간의 측정이 어려운 형태”에 대해서는 정산을 하려 해도 현실적으로는 문제가 발생할 수 있다고 언급한다.

그러므로 예외적 인정설, 예외적 부정설 모두 ‘근로시간의 측정’이 가능하지 않은 경우이거나 ‘근로기준법에 따라 임금을 산정’할 수 없는 경우에 정산의 과정을 거치지 않고 포괄임금제의 효력이 인정되므로 포괄임금제는 ‘정산가능형’과 ‘정산곤란형’으로 구분할 수 있다고 한다.³⁹⁾

복수 유형설에 의하면 정산가능형 포괄임금제는 포괄임금을 근로기준법에 따라 산정한 임금과 정산하여 근로자에게 차액을 지급하여야 한다.⁴⁰⁾

(4) 검토

앞서 살펴본 바와 같이 판례가 규정하고 있는 포괄임금제의 성격은 예외적 인정설과 예외적 부정설로 나누어진다.

예외적 인정설에 근거한 판례를 살펴보면 실제 근로시간을 산출하기 어려운 경우에 한하기는 하나, 실근로시간을 쉽게 산정 가능하거나 연차휴가수당이나 주휴수당에 관한 포괄임금제가 유효하게 성립할 수 있다고 판시한 판례가 있고,⁴¹⁾ 판례가 사용하는 “근로시간, 근무 형태, 업무의 성질을 참작하여”라는 표현이 일정한 경우에 한하여 체결된 계약만을 적용하는 것은 아니라는 점에 비추어 볼 때,⁴²⁾ 이 견해를 수긍하기에는 어렵다.

38) 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 『노동법학』, 제29호, 한국노동법학회, 2009, 335면.

39) 노동법실무연구회, 앞의 책, 283면.

40) 하갑래, 앞의 논문, 336면.

41) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결.

42) 노동법실무연구회, 앞의 책, 283면.

판례의 변화를 살펴보면, 포괄임금제의 유효성과 관련하여 근로기준법을 적용하기 곤란하거나 근로시간을 산출하기 어려운 경우로 제한하여 판단해온 것이 아닌 것을 알 수 있다. 포괄임금제의 유효성 판단에서 중점을 두고 있는 것은 “근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때”로 보인다. 즉, 판례는 포괄임금제의 적용 대상을 광범위하게 판단하고 있는 것으로 보인다.

정리해보면, 예외적 인정설에서 주장하고 있는 예외적인 경우에만 포괄임금제가 인정된다는 주장은 받아들이기 어렵다. 예외적 부정설의 입장이 판례법리에 더 가까운 것으로 생각된다. 복수 유형설은 포괄임금제의 적용 대상에 대하여 두 가지 유형을 절충한다는 입장에서 주목할 만하다고 생각한다.

2. 포괄임금제 적용 대상

포괄임금제의 적용 대상과 관련하여 적용될 수 있는 경우를 제한할 것인지(이하 대상 제한론이라 한다), 제한할 필요가 없다고 볼 것인지(이하 불이익성론이라 한다)에 관하여 두 가지 견해가 존재한다.⁴³⁾

(1) 대상 제한론(적용 대상 제한론)

대상 제한론은 포괄임금제에 관하여 판례가 예외적으로 인정하는 제도라고 보는 견해이다.⁴⁴⁾ 이 견해는 업무의 성격이나 근로의 형태가 불규칙하거나 근로자의 실제 근로시간 산출이 불가능한 경우에 한하여 제한적으로 포괄임금제를 인정해야 한다고 본다. 업무의 성격상 실제 근로시간의 산출이 가능함에도 단순히 계산 편의를 위해 포괄임금제를 인정하는 것

43) 강성태, 앞의 논문, 253면에서는 두 견해를 대상 제한론과 불이익성론으로 언급하고 있다. 한편, 노동법실무연구회, 앞의 책, 284면에서는 엄격해석론과 확대해석론으로 언급하고 있다. 본 논문에서는 논문의 취지에 보다 가까운 대상 제한론과 불이익성론으로 표기한다.

44) 문형배, 앞의 논문, 716면, 송명호, 앞의 논문, 59면, 이국환, 앞의 논문, 349면.

은 근로기준법의 원칙을 위반하는 것이기 때문에 근로자의 실제 근로시간을 잠탈할 우려가 있으므로 허용되지 않는다고 한다.⁴⁵⁾

(2) 불이익성론(적용 대상 비제한론)

불이익성론은 포괄임금제 성격 논의와 관련하여 예외적 부정설에 따른 견해이다.⁴⁶⁾ 이 견해는 업무의 성질이나 근로형태의 특수성에 대하여 근로시간 산정이 불가능한 경우에 한하지 않고 근로시간 산정이 가능한 경우라도 개별 사안에 따라 근로자의 근무 의욕 고취와 계산의 편의를 위해 포괄임금제의 임금 약정을 할 수 있다고 보는 견해이다.⁴⁷⁾ 그러나 이 견해는 포괄임금 약정이 근로자의 근무 의욕 고취와 계산의 편의만을 위한 것이기만 하면 항상 유효하다고는 보고 있지 않으며, 포괄임금제의 적용 대상은 될 수 있지만 유효성은 근로자에게 불이익한지에 따라 결정해야 한다고 본다.⁴⁸⁾ 이 견해는 2010년 대법원판결⁴⁹⁾ (근로시간 산정이 어려운 경우에만 포괄임금을 허용) 이전에 나온 학설이다.

(3) 검토

대상 제한론은 포괄임금제의 대상이 되는 업무를 제한하는 입장으로 정리할 수 있다.⁵⁰⁾ 이 견해는 판례에서 언급하고 있는 ‘근로자의 승낙’을 보다 엄격하게 해석한다. 판례가 포괄 산정 임금을 근로자가 동의 없이 수령 하였다는 이유만으로 근로계약 체결 시 포괄임금제에 대하여 묵시적으로 승낙하였다고 보기는 의제적인 해석이라고 비판하고 있다. 또한, 근로 형태의 성질상 연장 및 야간근로 등을 전제로 근로계약이 체결

45) 문형배, 앞의 논문, 716면, 이국환, 앞의 논문, 349면.

46) 김지형, 앞의 논문, 165면.

47) 김지형, 앞의 논문, 165-166면.; 신수길, 앞의 논문, 193면.

48) 김지형, 앞의 논문, 165-166면.

49) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.

50) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 『노동법연구』, 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2009, 254면.

되었다는 사정만으로 포괄 임금 계약이 체결되었다는 취지로 판시한 판례 역시 옳지 않다고 주장한다.

불이익성론은 포괄임금제의 성립요건과 유효요건을 구분하는 견해이다. 이 견해는 판례에서 언급하고 있는 유효요건은 “근로자에게 불이익이 없고, 제반 사정에 비추어 정당하여야 한다.”라고 판시한 부분이라고 본다. 또한, 포괄임금제는 근로계약 당사자 사이 임금 지급의 한 방식으로 자유롭게 약정할 수 있는 임금 지급계약의 형태라고 주장한다.⁵¹⁾

앞서 살펴본 것처럼 판례가 예외적 부정설의 입장에 있다고 볼 때 적용 대상 역시 불이익성론이 타당하다고 본다. 대상 제한론의 입장에서 판단하기에는 2가지 입장에서 한계가 있다. 우선 법에서 임금산정 방식에 개입한다는 것은 대다수 국가의 법제에서는 사례가 없고, 현행법 또한 임금산정에 개입하고 있지는 않다는 것이다.⁵²⁾ 불이익성론 역시 경제적인 압력을 통해 연장근로를 제한한다는 문제가 있지만, 포괄임금제를 적용한다고 해도 근로시간 규제가 가능하다. 포괄임금제를 적용하여도 근로시간의 배치와 길이는 규정하여야 한다. 근로시간의 길이나 배치를 규정하지 않는 것은 근로기준법의 취지에 위반될 뿐만 아니라 근로자가 사용자에게 일정 시간 동안만 노동력의 처분을 맡기는 근로계약의 본질에도 반한다.⁵³⁾

3. 포괄임금제 유효요건

포괄임금제의 유효요건으로는 종전 판례 법리 구조에 따라 세 가지로 구분할 수 있다. ① 근로시간 및 근로 형태와 업무의 성질 등을 참작하여 계산의 편의와 직원의 근무 의욕을 고취하기 위한 것이어야 하며, ② 근로자의 승낙이 수반되어야 하며, ③ 취업규칙 및 단체협약에 비추어 근로자

51) 신수길, 앞의 논문, 194면.

52) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 271면.

53) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 271면.

에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정되어야 한다.⁵⁴⁾

위와 같은 유효요건을 다 갖춘 경우, 포괄임금제가 자유롭게 활용되는 것이 아니라 예외적으로만 인정된다고 하여 ‘예외적 인정설’이라고 한다.⁵⁵⁾

예외적 인정설을 부정하는 입장(예외적 부정설)에 의하면 첫 번째 요건은 포괄임금제 임금 약정을 판단하기 위한 징표일 뿐이고, 두 번째 요건인 근로자의 승낙은 포괄임금제 계약의 성립요건에 해당하며, 세 번째 요건만 유효요건에 해당한다고 주장한다.⁵⁶⁾

대부분의 학설은 예외적 부정설의 입장을 취하고 있다.⁵⁷⁾ 사건으로도 예외적 부정설이 타당하다고 생각한다. 그 이유로는, 예외적 인정설이 주장하고 있는 첫 번째 요건인 “근로시간, 근로 형태와 업무의 성질 등을 참작하여 계산의 편의와 직원의 근무 의욕을 고취” 한다는 것은 포괄임금제의 유효요건이 아닌 포괄임금제 계약의 배경에 해당하기 때문이다.

판례는 포괄임금제의 유효성을 인정하는 업무로 기상 조건에 의해 근로시간이 변경되는 업무,⁵⁸⁾ 운행경로 및 교통상황에 따라 근무 시간이 일정하지 않은 버스 운전사,⁵⁹⁾ 감시·단속적 업무로써 상대적으로 육체의 피로가 덜한 아파트 경비 업무⁶⁰⁾이거나 야간 경비 업무,⁶¹⁾ 관리·감독·기밀 취급 업무, 일정 사무직 근무 등에 대해서는 인정하고 있다. 또한, 판례가 ‘근로시간, 근로 형태 및 업무의 성질’이라는 표현을 사용하고 있다는 점에서 근로가 일정하게 정해진 근로 형태에 대해서는 포괄임금제가 유효하게 성립하지는 않는 것으로 보인다. 즉, 포괄임금제 약정의 기준이 되는 근로시간, 근로 형태 및 업무의 성질은 유효성 판단에 있어 종합적으로 검토되어야 할 여러 사정 중 하나일 뿐 포괄임금제 적용 대상 여부 전

54) 노동법실무연구회, 앞의 책, 286면 참조.

55) 김홍영, 앞의 논문, 2011, 847면.

56) 김지형, 앞의 논문, 163-164면.

57) 김기선, 앞의 논문, 147면, 김도형, 앞의 논문, 191면, 임상민, 앞의 논문, 100면, 김홍영, 앞의 논문, 847면, 노동법실무연구회, 앞의 책, 286면.

58) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카15939 판결.

59) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카6934 판결.

60) 대법원 1983. 10. 25. 선고 83도1050 판결.

61) 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결.

체를 판단하는 것으로 보아서는 안 되며, 독자적 유효요건으로 보기에 그 한계가 존재한다.⁶²⁾

한편 대법원은 근로시간과 관련하여 “근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 근로시간수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결하는 것은 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다.”라고 판시⁶³⁾하였다. 이는 포괄임금제 계약과 관련하여 ‘근로시간의 산정이 어렵지 않은 경우’와 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’로 나눌 수 있다는 것으로 ‘근로시간의 산정이 어렵지 않은 경우’에는 근로기준법에서 규정하는 최저기준에 미달하는 포괄임금제 계약은 근로자에게 불이익하기에 무효로 예외적 부정설의 입장을 표하고 있는 것으로 보인다.

두 번째, 판례가 사용하고 있는 ‘근로자의 승낙’과 관련하여 별도의 유효요건으로 판단해야 할지, 당연한 성립요건으로 판단해야 할지 문제 된다.⁶⁴⁾

다수설은 ‘근로자의 승낙’이라는 표현을 통상 계약의 성립요건인 약정 또는 승낙의 의미로 보면서 포괄임금제 유효요건의 하나라고 주장한다.⁶⁵⁾ 다수설의 입장으로 한 견해는, 근로시간을 비롯한 휴일 및 휴계에 대하여 법정 기준과 다른 근로조건을 설정할 시 일정한 절차를 요구하는 경우가 적지 않은 것에 비추어 볼 때,⁶⁶⁾ 포괄임금제 약정에서 근로자의 승낙을 요구한다는 의미는 근로자의 자발적 의사에 따른 승낙이 필요하다는 것이라고 해석해야 한다고 본다.⁶⁷⁾ 절차적 요건을 엄격한 기준으로 판단해야 하는 것으로 이해되지만, 포괄임금제 약정과 관련한 승낙은 당연히 근로자의 자발적 의사에 의한 승낙이므로 자발적 의사에 의하지 않

62) 노동법실무연구회, 앞의 책, 290면.

63) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.

64) 노동법실무연구회, 앞의 책, 291면.

65) 문형배, 앞의 논문, 716면, 신수길, 앞의 논문, 193면, 이국환, 앞의 논문, 348면 참조.

66) 근로기준법 제51조 탄력적 근로시간제 및 근로기준법 제52조 선택적근로시간제에서 근로자대표와 서면합의, 근로기준법 제53조 연장근로와 관련하여 근로자와 합의.

67) 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 『인권과 정의』, 제37호, 대한변호사협회, 2005, 74면.

는 승낙에 대해서는 약정이 성립될 수 없다.⁶⁸⁾ 그러므로 자발적 의사에 따른 승낙이 독자적인 의미를 가진 유효요건이라고 볼 수는 없다.

세 번째, “근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 것”은 예외적 인정설이나 예외적 부정설 모두 포괄임금제의 성립 및 효력을 인정할 수 있는 실질적인 유효요건으로 보고 있다. 실제 사례에서 정당성의 판단이나 불이익성의 판단과 관련하여 판례는 기준을 엄격하게 제시하고 있지 않은 것으로 보인다.⁶⁹⁾

판례는 취업규칙 및 단체협약에서 임금 지급 기준이 상세하게 규정되어 있는 경우에 규정의 기준에 비추어 판단하여 불이익하지 않아야 한다지만,⁷⁰⁾ 특정직의 직원들에게 포괄임금제 규정을 일률적으로 적용하는 근로계약서는 그 성격상 취업규칙에 해당하므로, 해당 근로계약의 내용에 비추어 불이익 여부를 판단해야 하는 것이지, 일반직의 직원들에게 적용되는 취업규칙의 내용에 비추어 불이익 여부를 판단해야 하는 것은 아니라고 판시⁷¹⁾한다. 판례에 따르면 포괄임금제가 근로자에게 불이익하지 않다고 해석이 가능하게 된다.⁷²⁾

한편, “제반 사정에 비추어 정당해야 한다.”는 것은 단체협약 및 취업규칙을 비롯하여 동일 노동·동일 임금의 원칙 외에도 개별 요소들, 가령 포괄임금제 이전의 연장근로수당 등의 지급 실태나 동일한 업종의 근로자 임금 수준 등 기타 사정을 고려하여 정당해야 한다는 취지이다.⁷³⁾

68) 노동법실무연구회, 앞의 책, 291면 참조.

69) 김홍영, 앞의 논문, 848면.

70) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결 등.

71) 대법원 1992. 2. 28. 선고 91다30828 판결.

72) 단체협약 및 취업규칙에 비추어 불이익한다는 판단은 휴일근로시간, 연장근로시간의 한도가 규정된 당해 단체협약 및 취업규칙이, 포괄임금제가 적용된다는 근로자들에게도 동일하게 적용되는 경우에만 양측을 비교하여 포괄임금제의 효과를 제한할 수 있을 뿐이다. 대법원 1992. 7. 14. 선고 91다37256 판결; 김홍영, 앞의 논문, 848면, 각주 10번 재인용.

73) 송명호, 앞의 논문, 82면.

4. 포괄임금제에 해당하는 수당의 범위

포괄임금제의 임금 약정에 해당하는 범위로 대법원은 연장근로수당 및 야간근로 수당 뿐만 아니라 휴일근로 수당, 주휴수당, 연차휴가 수당 등도 포함된다고 한다.

이와 관련하여 판례는 “주휴수당이나 연차휴가 수당이 법에서 정한 기간을 근로하였을 때 비로소 발생하는 것이라 할지라도 당사자 사이에 미리 그러한 소정 기간의 근로를 전제로 하여 주휴수당이나 연차휴가 수당을 일당 임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 것이 불가능한 것이 아니며, 포괄임금제란 각종 수당의 지급 방법에 관한 것으로 근로자의 연차 휴가권의 행사 여부와는 관계가 없으므로 포괄임금제가 근로자의 연차 휴가권을 박탈하는 것이라고 할 수 없다.”라고 판시⁷⁴⁾하여 포괄임금제에 해당하는 임금에 주휴수당 및 연차휴가 수당도 포함된다고 하였다. 또한 휴일근로 수당 역시 포괄임금제에 포함된다고 하였지만,⁷⁵⁾ 퇴직금은 포괄임금제에 포함되지 않는다고 하였다.⁷⁶⁾

한편 휴일근로 수당 및 연차휴가 미사용 수당과 관련하여 사전에 포괄임금에 포함하는 약정을 하는 것은 모순이 있으며 근로자에게 휴식권을 보장하기 위한 휴일의 사용이 실질적으로 제약된다는 점을 들어 판례를 비판하는 견해도 존재한다.⁷⁷⁾ 이 견해를 반박하는 견해⁷⁸⁾의 주장으로 연장·야간 근로수당도 일정한 연장·야간근로를 전제로 사전에 포괄임금에 포함하는 것이기에 일정한 휴일근로 또는 연차휴가일의 근로를 전제로 사전에 휴일근로 수당이나 연차휴가 미사용수당을 포괄임금에 포함시키는 것은 허용된다고 주장한다.⁷⁹⁾

74) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결.

75) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결.

76) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결.

77) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 『노동법연구』, 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2009, 273면, 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 『노동법학』, 제29호, 한국노동법학회, 2009, 339면.

78) 노동법실무연구회, 앞의 책, 295면.

79) 송명호, 앞의 논문, 73면.

결론부터 언급하자면 휴일근로 수당 및 연차휴가 미사용 수당은 포괄임금에 포함하지 않는 것이 옳다고 생각한다. 연장·야간 근로수당은 근로가 지속되는 중에 발생하는 수당이므로 포괄임금에 포함할 수도 있지만, 휴일근로 수당 및 연차휴가 미사용은 근로자에게 근로자 잠시나마 단절된 상태에서 나오는 수당이므로 이를 포괄임금에 포함하면 근로자의 휴식권인 휴가, 휴일이 온전히 보장받지 못하는 구조로 나타나기 때문이다.

5. 소결

포괄임금제가 내재하고 있는 가장 큰 문제점은 가산임금의 대상이 되는 근로시간 제한에 어떠한 제한도 있지 않고, 포괄 산정할 수 있는 법정제 수당의 종류에 아무런 제한이 없다는 것이다.⁸⁰⁾ 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 포괄임금제에 일정한 한계를 설정하여 제한하는 것이 타당하다. 포괄임금제의 제한은 두 가지 측면을 고려하여 실행하여야 한다.

첫 번째, 사업장에서 포괄임금제를 채택하는 경우 근로자 대표의 동의 및 근로자 본인의 명시적 동의가 있어야 한다. 두 번째, 원칙적으로는 가산임금의 대상이 되는 연장근로 및 휴일근로에 대하여 포괄임금제에 포함할 수 있는 근로시간을 월(月), 년(年) 단위로 한도를 정하여 엄격하게 제한하여야 한다.

오랜 시간 동안 판례법리에 의해 축적되어온 포괄임금제를 단기간에 폐지하기에는 근로 현실에 비추어 볼 때 현실적으로는 한계가 존재한다. 하지만, 근로자의 임금 및 근로시간과 직결된 문제이므로 엄격하고 제한적으로 포괄임금제의 유효성을 인정하여야 한다.

80) 강성태, “근로기준법상 임금제도의 개선방향에 관한 연구”, 『노동법연구』, 제10호, 서울대학교 노동법연구회, 2001, 181면, 문무기 외 3인, “임금제도 개편을 위한 노동법적 과제”, 『한국노동연구원』, 연구보고서, 2006, 202면.

IV. 포괄임금제의 개선을 위한 방안

1. 포괄임금제 개선의 필요성

포괄임금제의 가장 큰 문제점인 장시간 노동을 고착하는 현상을 해결하기 위해서는 입법적 해결방안으로 그 해결책을 찾아야 한다.⁸¹⁾ 포괄임금제는 연장근로 및 야간근로, 휴일근로를 항상 수반한다는 것을 전제로 하고 있다. 즉, 포괄임금제가 유효하다고 보는 것은 상시적인 장시간 근로를 합법화하여 유지한다는 것이다.⁸²⁾

하지만 장시간 근로를 억제하기 위해 포괄임금제를 규제해야 한다는 주장에 대해서는 좀 더 넓은 시야로 바라볼 필요성이 있다. 가령 앞서 언급한 사무직의 경우, 사무직의 포괄임금성을 인정하기에는 대부분의 사무직이 근로시간 산정이 어려운 경우가 많지 않기 때문이다. 사무직 근로에서 일정한 시간만을 연장근로 등으로 인정하는 관행을 근로기준법에 비추어 본다면, 연장근로 등의 한도만을 규정한 것이어서 포괄임금제의 약정이라고 판단하기에는 어렵다. 설사 포괄임금제의 약정이라고 판단하더라도 유효요건이 성립하지 않기에 실 근로시간에 따라 차액을 사용자가 지급해야 한다.

위와 같은 문제에 한하면 포괄임금제의 개선과 관련하여 제한하거나 금지하는 전체적인 틀에서 입법적인 해결방안보다는 범위반사례가 발생하지 않도록 근로감독을 강화하는 방안이 필요하다.⁸³⁾ 실 근로시간에 따라 근로자가 임금을 정산받을 수 있도록 회사가 출·퇴근 등 근로시간을 엄격하게 관리하도록 하며, 이에 더하여 현 판례법리를 기준으로 위반사례가 나오지 않도록 근로감독을 강화해야 한다.⁸⁴⁾

한편, 포괄임금제의 약정이 그 자체로 유효하다고 인정된다면, 근로기

81) 김홍영, 앞의 논문, 851면.

82) 심재진, “포괄임금제의 쟁점과 전망”, 『노동법학』, 제64호, 한국노동법학회, 2017, 65면.

83) 도재형, “포괄임금제 금지 공약에 더해”, 한국일보, 2017. 5. 7. (검색일자: 2023. 5. 1.)

84) 심재진, 앞의 논문, 66면 참조.

준법 제56조 가산임금 규정의 예외 규정으로 인정되는 것이다. 예외를 인정하게 되면 가산임금 규정을 통해 초과근로를 제한하는 근로기준법 제56조의 목적에 어긋나는 결과를 초래한다. 이러한 문제점은 야간근로와 관련하여 연소자와 임신 중인 여성에 대한 보호(근로기준법 제70조)를 무효화할 수 있다는 해석도 가능하게 된다.⁸⁵⁾

포괄임금제가 유효하기 위해서는 사용자와 근로자의 합의가 항상 존재한다고 볼 수 있다. 만약 연장근로가 필요할 때마다 당사자의 합의가 필요하다면 연장근로의 요건을 충족하지 못하게 된다. 이는 휴일근로도 동일하게 적용된다.⁸⁶⁾ 또한, 포괄임금제에 연차휴가 근로 수당이 포함된다 고 약정하게 되면 근로자의 휴식권인 연차 휴가를 침해하는 결과를 초래하게 된다. 결론적으로 포괄임금제는 근로기준법상의 규정들에 어긋나는 측면이 존재한다.

이러한 문제점들은 결국 근로기준법의 근로시간 유연화제도 적용에 많은 영향을 미친다. 말 그대로 임금을 ‘포괄’하는 것이기에 재량근로제의 경우 재량근로와 관련된 요건을 갖추지 않아도 포괄임금제 약정이 유효하다고 성립되면 사용자는 근로자 대표와의 서면합의를 필요로 하는 재량근로제를 도입할 필요가 없다.⁸⁷⁾ 감시·단속적 근로와 관련하여 적용제외 승인을 받지 않아도 포괄임금제가 유효하게 성립된다면 사용자 측에서는 일정한 요건을 갖추어야 하는 적용제외 승인을 신청할 필요가 없게 된다. 적용제외 승인 신청을 하지 않아도 포괄임금제를 통해 기대하는 목적을 달성하게 되기 때문이다.

2. 포괄임금제의 제한

포괄임금제를 제한하기 위해서는 일정한 한계를 설정한 후, 예외적으로

85) 하갑래·최미나, “포괄임금제의 운영실태 및 개선방안에 관한 연구”, 『고용노동부학술연구용역보고서』, 2012, 112면.

86) 심재진, 앞의 논문, 66면.

87) 심재진, 앞의 논문, 66면.

허용하는 방안을 제시한다.⁸⁸⁾ 연장근로 및 휴일근로에 대하여 월(月), 년(年) 단위로 한계를 설정하여 포괄임금제에 포함하는 한도를 정해야 한다. 또한, 포괄임금제가 유효하게 성립하기 위해서 근로자 대표의 동의 및 근로자의 명시적 동의를 얻어야 한다.⁸⁹⁾ 근로자 본인의 동의가 필요하다는 점에서 대부분 근로자 대표와의 서면합의를 필요로 하는 유연화 제도보다 요건이 더 엄격해지게 된다. 기존의 다른 유연화 제도, 근로시간 적용 제외 조항 대상 업무와 중복될 수 있다거나 재량근로제와 유사하다는 견해⁹⁰⁾도 존재하지만 이러한 문제점을 해결하기 위해서 포괄임금제 도입방식에서 다른 유연근로시간제와 균형을 고려하여 근로자대표와 서면합의를 요건으로 하는 방안을 규정해야 한다.⁹¹⁾ 추가적인 제한사항으로 포괄임금제는 “근로시간의 산정이 어려운 경우”만으로 한정하고 다른 근로시간 유연화 제도, 사업장 밖 간주근로시간제와 근로시간 적용제외 및 재량근로제의 업무는 포괄임금제를 금지하는 것이다.⁹²⁾ 추가적인 제한사항을 설정하면 기존 유연화제도와 충돌되지 않는 결과가 발생한다. 또한, 현행 판례법리로 인정되고 있는 포괄임금제 허용 업무가 협소해지게 된다. 대표적으로 근로기준법 제63조에서 규정하고 있는 적용 제외 업무인 감사·단속적 근로는 포괄임금제가 허용되지 않게 된다. 또한, 사업장 밖 근로 및 재량근로제도 포괄임금제가 허용되지 않게 된다.

3. 포괄임금제의 순차적 폐지

포괄임금제는 장시간 근로를 조성하고, 근로자의 인권을 침해하는 근로 형태를 보이고 있다. 또한, 근로기준법에서 규정하고 있는 근로시간 제한 규정에 벗어나는 모습을 보인다. 포괄임금제는 판례 법리에 의해 축적되

88) 강성태, “근로기준법상 임금제도의 개선방향에 관한 연구”, 182면.

89) 강성태, “근로기준법상 임금제도의 개선방향에 관한 연구”, 181-182면.

90) 심재진, 앞의 논문, 69면.

91) 하갑래·최미나, 앞의 연구용역보고서, 137면.

92) 하갑래·최미나, 앞의 연구용역보고서, 131-133면.

어은 제도로, 이러한 문제점을 해결하기 위해서 순차적으로 폐지하는 방안을 제시한다.

포괄임금제의 무조건 적인 폐지에 앞서 현행 근로시간 유연화제도를 보완해야 한다. 예를 들어 재량간주근로시간제의 경우 전문업무형 대상 업무를 확대하거나 기획업무형을 신설하고, 사업장 밖 간주근로시간제는 야간·휴일근로에도 간주제가 적용됨을 명시하고, 근로시간 적용 제외는 휴일근로수당을 제외하고 관리·감독적 업무에 대한 판단기준을 규정하는 방안 등이다.⁹³⁾ 이에 더하여 포괄임금제를 폐지하기 위해서는 근로기준법 제56조를 개정하는 방안으로 그 해결책을 찾을 수 있다.

임금 및 가산임금에 관한 규정을 ‘각각의 임금 항목이 다른 임금 항목에 포함되어 있는 것을 간주하거나 해당 근로시간과 관계없이 일정한 금액을 지급할 수 없다.’라고 규정하거나,⁹⁴⁾ ‘임금을 총임금이나 정액 수당에 미리 포함하여 산정하여서는 아니 된다.’라는⁹⁵⁾ 단서 조항들을 추가하는 것이다.

4. 소결

포괄임금제가 내재하고 있는 문제점을 해결하기 위해서는 포괄임금제를 제한하거나 폐지하는 방안으로 해결책을 찾아야 한다. 2009년 대법원 판결⁹⁶⁾을 통해 포괄임금제의 성립 및 유효성에 관하여 과거보다 다소 엄격하게 판단하고 있지만, 앞으로 더 엄격하게 성립 및 유효성을 판단할 거라고 기대하기에는 어려운 현실이다. 포괄임금제와 관련한 판례법리는 기본 틀에서 크게 변하지 않은 채 발전해왔기 때문이다. 판례법리의 특성상 개별 사례들이 발생하였을 때 판단·발전하는 방식이기에 일시적으로 큰 틀에서 엄격하게 변화될 것이라고 기대하기에는 어렵다. 결국, 포괄임

93) 하갑래·최미나, 앞의 연구용역보고서, 129면 참조.

94) 하갑래·최미란, 앞의 연구용역보고서, 121면.

95) 김홍영, 앞의 논문, 860면.

96) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결.

금제의 문제점을 해결하기 위해서는 명시적으로 제한하거나 폐지하는 방안으로 나아가야 한다.

포괄임금제를 제한하거나 폐지하더라도 근로시간 유연화 제도나 근로기준법의 조항과 중복되는 문제가 나타날 수 있으므로, 완전한 해결책이라고 보기에는 어렵다. 우선적으로 근로기준법의 제58조 및 제63조에서 규정하고 있는 대상이 중복되는 점을 해결해야 한다.⁹⁷⁾

포괄임금제의 제한과 폐지라는 용어의 표현으로 인해 두 가지 입법안이 차이가 있다고 볼 수도 있지만, 현실적으로는 그리 크지 않을 것으로 보인다. 제한적인 입법안에서는 제58조 및 제63조에서 규정하고 있는 대상 업무가 배제되기 때문에 이 대상업무들을 제외하면 포괄임금제에서 허용되는 업무의 범위는 한정적으로 나타난다. 반면 포괄임금제 폐지를 적용하면 근로시간의 산정이 현실적으로 불가능한 경우 근로기준법에 위반된다는 것을 입증하기 어렵기 때문에 현실적으로는 포괄임금제를 어쩔 수 없이 허용되는 경우가 발생할 수 있다.

보다 더 나은 해결책을 찾기 위해서는 포괄임금제를 폐지하는 방안으로 해결책을 찾아야 한다고 생각한다. 포괄임금제를 폐지하게 되면 근로기준법에서 규정하고 있는 근로시간 산정 원칙을 명확하게 한다는 점에서 더 옳다고 생각한다. 단, 근로시간 산정이 현실적으로 어렵거나 불가능한 업종에 한해서는 예외적인 조항을 만들어야 한다.

V. 결론

‘포괄임금제’는 그 자체로 법정수당 및 가산임금을 무효화시키고 근로기준법에서 규정하고 있는 근로시간을 침해할 소지가 큰 제도이다.

우선 해석론에서는 판례법리의 판단 구조에 의해 포괄임금제의 성립 여부 및 유효성을 중심으로 살펴 보았다. 최근 대법원은 포괄임금제의 약정

97) 심재진, 앞의 논문, 73면.

여부에 관하여 이전 판결들보다 엄격한 기준을 제시하고 있다. 이에 더하여 대법원은 포괄임금제의 성립을 인정하더라도 근로시간의 산정이 어려운 경우 실제 근로시간에 의해 산정된 가산임금보다 포괄임금제에 의해 지급되는 수당이 적으면 유효하지 않은 것임을 명확하게 하여 유효성 판단에 있어서도 그 기준을 엄격하게 하고 있다.

하지만 대법원이 이런 엄격한 기준을 제시함에도 불구하고, “근로시간의 산정이 어려운 경우”에 대해서는 일관적이고 구체적인 기준을 제시하지 못하고 있다.

근로기준법에서 규정하고 있는 법정수당 및 가산임금, 근로시간은 강행규정이기에 포괄임금제가 성립하기 위해서는 이러한 강행규정을 위반하지 않는 선에서 운용되어야 한다. 앞서 살펴본 포괄임금제의 문제점을 해결하기 위한 개선방안을 정리해보면 다음과 같다.

기본급조차 정해져 있지 않은 정액급제는 폐지하여야 한다. 기본임금조차 정해져 있지 않은 정액급제는 그 자체로 근로자의 임금 및 근로시간을 침해할 소지가 크기에 정액급제를 유효하게 인정하고 있는 현재 판례의 법리는 변경될 필요성이 있다.

정액수당제와 관련하여서는 업무의 특성상 근로시간의 산정이 어려운 경우, 근로기준법을 위반하지 않는 선에서 포괄임금 약정은 유효하다고 볼 수 있다. 하지만, 근로시간 산정이 가능한 업무의 경우 근로기준법에서 규정하고 있는 법정수당 및 가산임금을 위반하는 경우 무효로 하여야 하며 무효인 부분에 대해서는 근로자에게 차액을 지급하여야 한다.

위와 같은 문제점이 발생하는 이유는 포괄임금제에 관하여 판례가 기준으로 제시하고 있는 “근로시간의 산정이 어려운 경우”라는 모호한 표현으로 인한 것으로 볼 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 보다 더 명확한 표현이 필요하다.

| 참고문헌 |

단행본

노동법실무연구회, 근로기준법주해Ⅲ, 제2판, 박영사, 2020.

이상운, 노동법, 제6판, 법문사, 2011.

이병태, 최신노동법, 제8판, (주)중앙경제, 2008.

임종률, 노동법, 제19판, 박영사, 2021.

하갑래, 근로기준법, 제25판, 중앙경제사, 2013.

학술지

강성태, “근로기준법상 임금제도의 개선방향에 관한 연구”, 『노동법연구』, 제10호, 서울대학교 노동법연구회, 2001.

강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 『노동법연구』, 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2008.

김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리”, 『법과 정책연구』, 제20집, 한국법정책학회, 2020.

김도형, “포괄임금약정에 관한 판례 법리의 검토”, 『노동판례 비평』, 제15호, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2011.

김수곤, “포괄역산 관행의 문제”, 『월간 경영계』, 전국경영자총협회, 1996.

김지형, “노동쟁송과 판례연구(하)”, 『인권과 정의』, 제319호, 대한변호사협회, 2003.

김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 『성균관법학』, 제23권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2011.

문형배, “포괄임금계약과 근로기준법 제61조”, 『판례연구』, 제11집, 부산판례연구회, 2000.

박주현, “포괄산정근로계약(포괄역산임금계약)과 근로시간”, 『노동법연구』, 제2권 제1호, 서울대학교 노동법연구회, 1992.

송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 『인권과 정의』, 제347호, 대한변호사협회, 2005.

신수길, “포괄임금제에 의한 임금지급계약이 유효하기 위한 요건”, 『대

- 법원판례 해설』, 제32호, 법원도서관, 1999.
- 심재진, “포괄임금제의 쟁점과 전망”, 『노동법학』, 제64호, 한국노동법학회, 2017.
- 이공희, “포괄산정임금제의 적용과 근로기준 판단”, 『노동교육』, 제37호, 한국노동교육원, 2003.
- 이국환, “감시단속적 근로와 포괄임금계약의 유효성”, 『대법원판례해설』, 제28호, 법원도서관, 1997.
- 이재용, “근로시간의 산정이 어려운 사정이 없는 경우 포괄임금계약의 효력”, 『법학연구』, 제43집, 한국법학회, 2011.
- 임상민, “포괄임금제의 성립 및 유효요건”, 『인권과 정의』, 제502호, 대한변호사협회, 2021.
- 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 『노동법학』, 제29호, 한국노동법학회, 2009.

신문기사 및 보도자료

- 도재형, “포괄임금제 금지 공약에 더해”, 한국일보, 2017. 5. 7. (검색일자: 2023. 5. 1.)

연구용역 보고서

- 문무기 외 3인, “임금제도 개편을 위한 노동법적 과제”, 『한국노동연구원』, 연구보고서, 2006.
- 정동관 외, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, 『한국노동연구원』, 연구보고서, 2016.
- 하갑래·최미나, “포괄임금제의 운영실태 및 개선방안에 관한 연구”, 『고용노동부 학술 연구 용역보고서』, 2012.

토론문

- 김홍영, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나 자료집, 2019.
- 이석, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나 자료집, 2019.

| 국문초록 |

본 글을 쓴 계기는 필자의 지인과의 대화에서부터 시작한다. 대기업에서 근무하고 있는 필자 지인의 질문은 연장근로를 하여도 ‘포괄임금제’에 따라 연장근로수당이 아닌 기본 근로수당만을 받는 임금형태에 대하여 필자에게 어떻게 생각하고 있는지, 과연 이러한 임금형태가 올바른 것인지에 관한 질문을 듣게 되었다. 이러한 질문에 대한 의구심들로 인해 포괄임금제가 무엇인지, 판례 법리상 현실적 편의성이라는 측면에서 성립 및 발전되어온 포괄임금제의 본질이 무엇인지에 대한 의문들이 본 글을 쓴 계기가 되었다.

이에 본 글에서는 포괄임금제와 관련하여 현실적으로 가장 문제가 되는 업종인 청원경찰 및 아파트경비원 등 24시간 격일근무제 형태에 대해서 살펴본다. 대부분이 고령자이거나 사회적 약자들인 아파트경비원 같은 업종의 경우 업무의 특성상 24시간 근무를 하는 경우가 많은데 이들은 ‘포괄임금제’라는 명목하에 기본급만 받고 연장근로수당은 받지 못하는 경우가 대부분이다. 판례법리에 의해 형성된 포괄임금제가 현실에서는 어떻게 적용되고 있는지 기존 판례들을 토대로 검토한다.

또한, 윤석열 정부의 3대 개혁안 중 현시점에서 가장 이슈가 되고 있는 노동 개혁, 그 중 근로시간에 관한 논의가 뜨겁다. 미래 노동시장 연구회는 기존의 1주 40시간제에 연장근로 12시간을 포함한 주 52시간 근로가 아닌, 1주 최대 69시간 근로 개편안을 발표하였지만, 과로로 인한 일과 삶의 균형이 침해될 것이라는 노동계의 반발로 인해 청년과 노동계의 의견을 청취한 보완을 검토 중이다. 필자의 사견이지만, ‘주 69시간 근로시간제를 논의하기에 앞서 현실에서 가장 문제가 되는 포괄임금제를 우선 논의해 보는 건 어떨까?’라는 의문 역시 본 글을 쓰는 목적에 포함된다.

판례는 1970년대부터 “통상임금과 이에 가산할 각종 수당의 산출이 사실상 불가능할 경우, 제 수당을 미리 합산한 일정금액을 월급여로 지급하는 것도 허용된다.”라는 판결을 통해 포괄임금제의 관행을 인정, 발전시켜왔다.

근로기준법은 1997년 근로시간 유연화라는 노동 현실 요구에 부응하기 위해 재량근로 간주 근로시간제, 사업장 밖 간주 근로시간제, 선택적근로 시간제, 탄력적근로시간제, 공익사업에 있어서 근로시간 특례 등 근로시간에 유연성을 부여하는 유연근로시간제를 도입하였다. 하지만 이와 별개로 기본임금을 기초로 가산수당을 산정하는 구조에 대한 예외적인 제도, 포괄임금제는 여전히 판례를 통해 적용 대상 및 요건, 효력 등을 보완하여 발전해오고 있다. 포괄임금제는 판례법리를 통해 발전, 인정되어 온 제도이다. 이러한 구조로 인해 여전히 학계를 중심으로 포괄임금제의 개념 및 대상, 요건, 효력 등에 대하여 해석론에서 다양한 논의가 이루어지고 있다. 본 글에서는 포괄임금제에 대한 다양한 논의 들을 검토하여 포괄임금제가 가지고 있는 문제점을 파악하고, 현실적인 해결방안을 찾는 것을 그 목적으로 한다.

주제어 : 포괄임금제, 근로시간, 가산수당, 간주근로, 유연근로시간제

Abstract

Legal Characteristics and Issues of the Comprehensive Wage System

Kim Hongsuk^{*}

The reason why I wrote this article begins with a conversation with my acquaintance. The complaints of my acquaintance working at a large company begin in the process of finding an answer to the question of how I feel about the wage type that receives only basic work allowances, not overtime pay, and whether this wage type is correct. Going one step further from this question, we will also look at the form of a 24-hour bi-day work system, such as the petition police and apartment security guards, which are the most problematic industries related to the comprehensive wage system. In most industries, such as the elderly or socially disadvantaged apartment security guards, they often work 24 hours a day due to the nature of their work, but most of them receive only basic wages and do not receive overtime pay. It examines how the comprehensive wage system formed by case law is applied in reality based on existing precedents.

In addition, among the three major reforms of the Yoon Suk Yeol government, discussions on labor reform, which is the most controversial at this time, are hot. The Future Labor Market Research Association announced a 69-hour workweek reform plan, not 52 hours a week, including overtime work, but is considering supplementing the opinions of young people and the

^{*} Ph.D., Chief Researcher, The Institute of Legal Studies, Konkuk University.

labor community due to opposition from the labor community. In my opinion, the question, “How about discussing the comprehensive wage system, which is the most problematic in reality, first before discussing the 69-hour workweek?” is also included in the purpose of writing this article.

Since the 1970s, precedents have recognized and developed the practice of the comprehensive wage system through a ruling that “if it is virtually impossible to calculate ordinary wages and various allowances to be added, it is also allowed to pay a certain amount of monthly salary.”

In 1997, the Labor Standards Act introduced a flexible working hour system that gives flexibility to working hours, such as discretionary working hours, considered working hours, selective working hours, flexible working hours, and special working hours for public works. However, apart from this, the exceptional system and comprehensive wage system for the structure of calculating additional allowances based on basic wages have still been developed by supplementing the subject, requirements, and effectiveness of application through precedents.

The comprehensive wage system is a system that has been developed and recognized through case law. Due to this structure, various discussions are still taking place in interpretation theory on the concept, target, requirements, and effect of the comprehensive wage system, centering on academia. The purpose of this article is to examine various discussions on the comprehensive wage system to identify the problems of the comprehensive wage system and to find realistic solutions.

Keywords: Comprehensive wage system, working hours, additional allowances, considered work, flexible working hours system